RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 10 – CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 64 – CIRC. N° 45 DE 2001
(ORD. N° 978 DE 19.04.2021).

Restructuración de grupo empresarial internacional.

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre los efectos tributarios frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta de una reestructuración de un grupo empresarial internacional.

I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, la sociedad "AAA", sociedad de responsabilidad limitada residente en Chile, es 99.9% propiedad de "BBB", una empresa holding residente en YYY.

Además de su participación en la sociedad chilena, "BBB" es propietaria y controladora de varias empresas subsidiarias residentes en Brasil, Estados Unidos, Perú, Portugal y YYY.

El 100% de las acciones "BBB" es propiedad de "CCC", entidad domiciliada en ZZZ, a través de la cual el grupo empresarial propietario (el "grupo") gestiona y controla sus inversiones alrededor del mundo.

Informa que el grupo evalúa una reorganización empresarial para poner término a sus actividades económicas en YYY. Dentro de este contexto, el grupo está interesado en el traspaso de todas las empresas subsidiarias desde "BBB" a "DDD", sociedad hermana del mismo grupo empresarial, residente en ZZZ y 100% propiedad de "CCC". En virtud del proceso de reorganización empresarial en curso, "DDD" se convertiría en la nueva sociedad holding mediante la cual se ejerce el control y propiedad directa de las empresas subsidiarias mientras "CCC" conserva la propiedad indirecta en su totalidad. Una vez cumplida esta etapa, el grupo disolvería a "BBB".

Un paso preliminar del referido proceso de reorganización empresarial ha sido el cambio de residencia tributaria de "BBB" por medio del traslado de su lugar de administración efectiva desde YYY a ZZZ, conforme al Convenio para evitar la doble tributación vigente entre ambos países. En consecuencia, "BBB" se reputaría residente en ZZZ.

Como consecuencia del proceso de reorganización empresarial, la totalidad de los derechos sociales de "AAA" sería transferida desde "BBB" a "DDD", permaneciendo "CCC" como propietario indirecto en todo momento. Para efectos de realizar el traspaso de los derechos sociales de la sociedad chilena, el grupo está analizando las tres opciones.

Al respecto, solicita confirmar lo siguiente:

1) Primera alternativa: transferencia de los derechos de AAA (Chile) desde BBB (YYY) a DDD (ZZZ), mediante un canje de derechos por acciones y su posterior aporte a una sociedad holding chilena con ocasión de su constitución. En este caso procedería la excepción contenida en el inciso quinto del artículo 64 Código Tributario, estando impedido el Servicio de tasar en la medida que el aporte de los derechos sociales de AAA – en primer lugar, a DDD y posteriormente a la holding chilena – resultante de este proceso de reorganización empresarial obedezca a una legítima razón de negocios y se cumplan los demás requisitos legales, incluyendo que los efectos tributarios de la reorganización se produzcan y agoten íntegramente en el país[1].

2) Segunda alternativa: aporte del 100% de las acciones de BBB (YYY), efectuado desde CCC (ZZZ) a DDD (ZZZ). Esta transacción podría no ser tasable, cumpliendo los requisitos del inciso final del artículo 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

3) Tercera alternativa: fusión entre DDD (ZZZ) y BBB (YYY), por medio de la cual esta última es absorbida. Igualmente, este Servicio no podría tasar en la medida que DDD mantenga registrado el valor tributario que tenían los derechos sociales de AAA en BBB (sociedad absorbida); la fusión se materialice bajo en régimen de neutralidad tributaria, sin generar pérdidas ni utilidades para sus intervinientes; y la fusión efectuada en el exterior produzca efectos jurídicos análogos a una fusión ocurrida en conformidad a la legislación chilena.

[1] Agrega que este requisito se cumpliría porque el aporte de los derechos sociales de una sociedad chilena (AAA) terminarían formando parte del activo de otra sociedad chilena (la nueva sociedad holding chilena), sometiéndose a la jurisdicción tributaria del país. La confirmación de este requisito reafirmaría el criterio sostenido por este Servicio en el Oficio N° 1433 de 2008.

II ANÁLISIS

Conforme al inciso quinto del artículo 64 del Código Tributario, este Servicio se encuentra impedido de tasar cuando se trate del aporte, total o parcial, de activos de cualquier clase, corporales o incorporales, que resulte de otros procesos de reorganización de grupos empresariales, que obedezcan a una legítima razón de negocios, en que subsista la empresa aportante, sea ésta, individual, societaria, o contribuyente del N° 1 del artículo 58 de la LIR, que impliquen un aumento de capital en una sociedad preexistente o la constitución de una nueva sociedad y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, siempre que los aportes se efectúen y registren al valor contable o tributario en que los activos estaban registrados en la aportante. Dichos valores deberán asignarse en la respectiva junta de accionistas, o escritura pública de constitución o modificación de la sociedad tratándose de sociedades de personas.

Dicho lo anterior y respecto de la primera alternativa que plantea en su presentación, para quedar inhibido el Servicio de sus facultades de tasación, es necesario que los efectos tributarios de la reorganización se produzcan y agoten íntegramente en el país[2], circunstancia que no se verifica cuando la empresa aportante de los derechos o acciones de una sociedad chilena como la que recibe el aporte son entidades constituidas en el exterior y sometidas a jurisdicciones tributarias extranjeras.

Luego, el aporte de derechos en una sociedad chilena desde BBB a DDD, podría ser objeto de tasación cuando el valor asignado a la operación resulte notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación.

En cuanto a la segunda alternativa de reestructuración empresarial, cabe tener presente lo dispuesto en los incisos tercero y siguientes al artículo 10 de la LIR, que contemplan casos de renta de fuente chilena.

El inciso tercero considera rentas de fuente chilena, afectas con el impuesto adicional del N° 3 del artículo 58 de la LIR, las rentas obtenidas por contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país en la enajenación de determinados títulos o instrumentos cuyos valores, en todo o parte, se encuentren representados por uno o más de los activos subyacentes situados en Chile que la disposición legal especifica.

Dentro de los activos subyacentes, se comprenden las acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo o entidad constituida en Chile. En la situación planteada, el activo subyacente estaría compuesto por derechos de una sociedad de personas constituida en el país.

Con todo, el inciso final del artículo 10 de la LIR libera de tributación con impuesto adicional a las enajenaciones ocurridas en el exterior efectuadas en el contexto de una reorganización del grupo empresarial cuando dicha reorganización no haya generado renta o un mayor valor para el enajenante determinada en cualquiera de las formas dispuestas en el N° 3 del artículo 58 de la LIR.

En términos generales, para no aplicar el impuesto adicional señalado, deben concurrir los siguientes requisitos copulativos:

a) Que la enajenación de activos efectuada en el exterior se realice en el contexto de una reorganización del grupo empresarial, según ésta se define en el artículo 96 de la Ley N° 18.045.

   De lo anterior se desprende que tanto el enajenante como el adquirente o receptor deben estar bajo un controlador común, de suerte que la propiedad o derechos de propiedad de personas jurídicas, entidades, sociedades o patrimonios constituidas, formados o residente en el extranjero, se mantengan bajo la propiedad directa o indirecta de un mismo dueño común.

b) Que no se haya generado en la operación una renta o mayor valor para el enajenante, determinado éste de acuerdo con cualquiera de las modalidades establecidas en el N° 3 del artículo 58 de la LIR. a elección del enajenante.

   Según los antecedentes expuestos en su presentación, el traspaso de los activos extranjeros, representativos de activos subyacentes situados en Chile, sería efectuado mediante el aporte del 100% de las acciones de BBB (YYY), desde CCC (ZZZ) a DDD (ZZZ).

[2] Por ejemplo, Oficio N° 2156 de 2013.

Dado lo anterior, y según los antecedentes expuestos en la consulta, la operación se enmarcaría en la hipótesis de excepción establecida en el inciso final del artículo 10 de la LIR, que libera de impuesto adicional la enajenación, en la medida que se efectúe en el contexto de una reorganización del grupo empresarial y siempre que no se haya generado renta o un mayor valor para el enajenante.

En estas circunstancias, la situación tributaria del contribuyente quedará en suspenso hasta que se enajenen los activos extranjeros en los términos establecidos del citado artículo 10 y se produzca un mayor valor.

En relación con la tercera alternativa (fusión entre DDD, domiciliada en ZZZ, y BBB, con domicilio en YYY, por medio de la cual esta última es absorbida), el inciso cuarto del artículo 64 del Código Tributario, en lo pertinente, impide tasar en los casos de división o fusión por creación o por incorporación de sociedades, siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el valor tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o aportante.

Al respecto, la Circular N° 45 de 2001, que impartió las instrucciones sobre la materia, instruyó que, para aplicar lo dispuesto en el inciso cuarto del referido artículo 64, las figuras jurídicas que indica la norma (división, fusión por creación y por incorporación) deben entenderse de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

El inciso cuarto del artículo 64 no establece requisitos en cuanto al lugar de constitución de las sociedades objeto de las fusiones[3]. Por tanto, en la medida que la fusión indicada en la tercera alternativa de su presentación se ajuste al concepto de fusión establecido en el artículo 99 de la Ley N° 18.046, y se mantenga registrado el valor tributario de los activos y pasivos en la sociedad que sucede a la o las sociedades disueltas, tendrá aplicación el inciso cuarto del artículo 64 del Código Tributario.

Con todo, si la fusión no puede entenderse comprendida dentro de aquella figura jurídica definida por la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y se produzca una transferencia de acciones o derechos sociales dentro del grupo empresarial internacional, sería aplicable el inciso tercero del artículo 64 del Código Tributario. Luego, si los efectos de la reorganización no se producen ni agotan íntegramente en Chile o la empresa aportante de los derechos o acciones de una sociedad chilena como la que recibe el aporte son entidades constituidas en el exterior y sometidas a jurisdicciones tributarias extranjeras, serían procedentes las facultades de tasación.

Finalmente, y cualquiera sea la alternativa implementada, corresponderá a las instancias de fiscalización verificar el cumplimiento de los requisitos legales en cada caso, lo mismo que los efectos tributarios del paso preliminar del proceso de reorganización empresarial consistente en el cambio de residencia tributaria de “BBB” desde YYY a ZZZ.

III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado, se informa que:

1) La transferencia de derechos de AAA (Chile) desde BBB (YYY) a DDD (ZZZ), mediante un canje de derechos por acciones, no cumple los supuestos del inciso quinto del artículo 64 del Código Tributario, pudiendo tasar este Servicio.

   En cambio, este Servicio estaría inhibido de tasar en el posterior aporte de los derechos a una sociedad holding chilena con ocasión de su constitución, en la medida que se cumplan las condiciones legales.

2) En la segunda alternativa, el aporte del 100% de las acciones de BBB (YYY), efectuado desde CCC (ZZZ) a DDD (ZZZ), podría liberarse de impuesto adicional y no ser susceptible de tasación, por aplicación del inciso final del artículo 10 de la LIR, cumpliendo los requisitos legales. Esto es, que la enajenación (aporte) de las acciones o derechos sociales se efectúe en el contexto de una reorganización del grupo empresarial, manteniéndose bajo la propiedad de un mismo controlador y sin generar renta o mayor valor para el enajenante.

3) En la fusión de sociedades extranjeras este Servicio estaría inhibido de tasar conforme al inciso cuarto del artículo 64 del Código Tributario, siempre que se mantenga registrado el valor tributario de los derechos de la sociedad chilena, se materialice bajo un régimen de neutralidad tributaria, sin

[3] Oficios N°1690 de 2019 y N° 2408 de 2017.

generar pérdidas ni utilidades para sus intervinientes, y la fusión efectuada en el exterior produzca efectos jurídicos análogos a una fusión ocurrida en conformidad a la legislación chilena.

Saluda a usted,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 978 del 19-04-2021
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos